

1505598-97.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 24/05/2022

... Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido. (RHC 192798 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021) (grifei)

Fixadas tais premissas, não há nulidade sem comprovação de prejuízo, observado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505598-97.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505598-97.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2107200/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17432655 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1036/21/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2107200 - DEL.POL.SALTO, 1036/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN CARLOS LIMA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu LUAN CARLOS LIMA SANTOS, por infração no art. 33, "caput" da Lei Federal nº 11.343/06, porque, em tese, no dia 19 de abril de 2021, por volta das 19h50min, na praça situada na Rua Hilário Ferrari, nº 328, Parque Residencial Marechal Rondon, nesta cidade e comarca de Salto/SP, o acusado, em ocasião de calamidade pública, nas imediações de recinto onde se realiza diversões de qualquer natureza, guardava e trazia consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito: a) 10 (dez) frascos de "lança-perfume" (cloroformo de metileno/diclorometano), com o volume de 58ml (cinquenta e oito mililitros); b) 07 (sete) porções de "maconha", com peso líquido de 3,35 (três gramas e trinta e cinco centigramas); c) 41 (quarenta e uma) porções de "cocaína", com peso líquido de 10,29g (dez gramas e vinte e nove centigramas); d) 27 (vinte e sete) porções de "crack", com peso líquido de 11,36g (onze gramas e

trinta e seis centigramas); e e) 26 (vinte e seis) porções de "crack", com peso líquido de 3,93g (três gramas e noventa e três centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi oferecida em 26 de maio de 2021 (fls. 126-132).

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 156-157).

A denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2021 (fl. 161-162) e o réu citado.

A legalidade do flagrante foi apreciada pela decisão fls. 68-70 que o considerou formalmente em ordem e decretou a prisão preventiva do réu.

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, preliminarmente alegou nulidade processual em razão da confissão informal aos guardas municipais, por não ser advertido do direito ao silêncio. Aponta ainda nulidade em razão de a prisão ter sido efetuada por guardas municipais, que não podem realizar atividades investigatórias. No mérito requereu a absolvição por falta de provas.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Respeitadas as alegações defensivas, as preliminares não merecem acolhimento.

Eventuais vícios na fase inquisitiva não contaminam o processo penal e a "confissão informal" prestada pelo investigado aos policiais militares é valorada apenas como prova testemunhal, já que os policiais externaram tal versão em Juízo. A respeito do tema, o I. Desembargador do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, Guilherme de Souza Nucci, com acuidade característica, destaca:

"A admissão de um fato criminoso, para ser considerada confissão, necessita ser produzida a quem esteja legalmente capacitado a ouvi-la. Chama-se, irregularmente, de confissão a declaração feita pelo acusado a terceiros, longe do recinto próprio. Um preso, admitindo ao policial que o transporta, por exemplo, ter matado a vítima, não está confessando na acepção jurídica do termo, mas somente fazendo uma declaração contrária ao seu interesse. Tanto assim que, não tendo forma legal, esse ato não será considerado confissão; poderá o policial prestar seu depoimento acerca do que viu e ouviu, mas a prova será testemunhal e jamais confessional". (Guilherme de Souza Nucci, in Provas no Processo Penal, 2015; p. 138)

Conforme ponderado pelo supracitado autor "não se nega que após a ocorrência de um crime, é possível à polícia obter do réu uma confissão ampla, tanto porque ele ainda não consultou seu advogado, como porque ainda não teve condições de pacificar o seu estado emocional, sempre alterado pela prática delituosa, equilibrando o raciocínio. Essa admissão de culpa pode até ser extraída de modo legítimo, sem coerção e sem tortura. Entretanto, levando-se em conta a possibilidade de ter sido feita sem qualquer garantia processual do acusado, jamais se poderia asseverar ser essa a real intenção do réu, qual seja a de confessar; nem mesmo se conseguiria assegurar não ter havido qualquer pressão ou sugestionabilidade no interrogatório policial. Se, em juízo, há magistrados que não sabem interrogar e nem se esmeram em aprender, porque haveria de agir com cautela o policial que, longe das vistas do advogado, da publicidade existente nas salas de audiência dos fóruns e da própria fiscalização do Ministério Público, está atuando isoladamente, em dependência própria e acostumado ao caráter inquisitivo da sua função?" (Guilherme de Souza Nucci, in Provas no Processo Penal. 2015; p. 189).

Além disso, a confissão extrajudicial, isoladamente considerada, não pode embasar uma condenação. Em hipótese semelhante, tem-se precedente do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravo da PGR. 3. Aviso de Miranda. Direitos e garantias fundamentais. A Constituição Federal impõe ao Estado a obrigação de informar ao preso seu direito ao silêncio não apenas no interrogatório formal, mas logo no momento da abordagem, quando recebe voz de prisão por policial, em situação de flagrante delito. 4. Inexistência de provas independentes no caso concreto. Nulidade da condenação. 5. Condenação por tráfico de drogas mantida. Absolvição do crime de associação para o tráfico. 6. Agravo improvido. (RHC 192798 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em

24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 01-03-2021 PUBLIC 02-03-2021)
(grifei)

Fixadas tais premissas, não há nulidade sem comprovação de prejuízo, observado também o artigo 566 Código de Processo Penal.

Rejeito ainda a preliminar de nulidade em relação à prisão efetuada pelos guardas municipais, considerando que qualquer do povo pode prender o flagrante e os guardas agiram após fundada suspeita, considerando que o réu estava em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e fugiu, com uma sacola na mão, após ser abordado pelos policiais.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls.01), boletim de ocorrência (fls.02-04), auto de exibição e apreensão (fl.05), auto de constatação preliminar (fls. 06-07) e laudo de exame químico toxicológico (fls.99-104) bem como por toda prova oral coligida nos autos.

A autoria do crime de tráfico também é certa.

Os guardas municipais Regis Conceição e Ronaldo Siqueira de Melo testemunhas comuns, foram uníssonos ao relatar em juízo que estavam em patrulhamento pelo Bairro Marechal Rondon e visualizaram três indivíduos em uma área de lazer, um quiosque, local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Ao notarem a aproximação da viatura da GCM, todos saíram correndo. Um dos rapazes chamou atenção por trazer consigo uma sacola plástica e saíram ao encalço deste último indivíduo, o qual adentrou em uma área verde e, durante a fuga, acabou caindo e machucando o joelho. Ele foi detido e identificado como sendo Luan Carlos Lima Santos. Na sacola havia 53 porções de crack, 41 microtubos contendo cocaína, 07 porções de maconha, 10 frascos plásticos contendo "lança-perfume", R\$ 265,00 reais em espécie, além de um celular que pertencia à namorada do acusado. Questionado, Luan afirmou ser gerente do tráfico de drogas naquele local há um mês, e que recebe quinhentos reais por semana.

O réu Luan Carlos Lima Santos, interrogado judicialmente, disse, em resumo que, na data dos fatos, comprou um pino de cocaína por R\$ 10,00 (dez reais). É usuário. Surgiu uma viatura da guarda municipal, os dois rapazes que estavam na biqueira correram, e ele permaneceu onde estava. Caiu no barranco. Os guardas o abordaram e o levaram para o mato. O agrediram com soco na costela e chutes e indagaram sobre uma sacola que eles tinham achado. Disse que não sabia de sacola nenhuma. Os guardas forjaram o flagrante. Somente na delegacia viu a droga que lhe foi atribuída. Os ferimentos são decorrentes das agressões dos guardas, e não da queda que sofreu do barranco.

Os guardas municipais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que o réu guardava e traziam consigo a droga e, após ser visto em um ponto conhecido pelo tráfico de drogas, ao perceber a aproximação dos agentes de segurança, tentou empreender fuga, sendo abordado com uma sacola plástica contendo diversos entorpecentes, confessando informalmente a prática da mercancia. As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

O mero fato de o acusado ser usuário não impede que ele exerça também a traficância, circunstância aliás que não se mostra incomum, devendo ser observado o artigo 28, inciso II, do Código Penal. A alegação de que o réu comprou um pino de cocaína, o flagrante foi forjado e ele foi agredido pelos guardas municipais não possui amparo na prova produzida nos autos. As testemunhas e o próprio réu disseram que o acusado sofreu uma queda num barranco e as lesões suportadas por ele (fls.

43/48 e laudo em fls. 107-108), aparentemente são compatíveis com a versão de que houve uma queda e o réu rolou do barranco. A respeito do ônus da prova em relação a fato novo suscitado pelo réu, confira-se a afirmação de Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do álibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o álibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, certo é que as circunstâncias da prisão, aliada à variedade de entorpecentes, à forma como estavam individualmente embaladas as drogas apreendidas, à apreensão de dinheiro e ao fato do local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas, indicam que as drogas eram destinadas à entrega e a consumo de terceiros, evidenciando o intuito mercantil e, corroborados pelos demais depoimentos colhidos em Juízo, são suficientes a embasar o decreto condenatório.

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes coma recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminosa e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável.

Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). Deve ser afastada a causa de aumento relativa ao local onde o crime foi cometido, afinal os entorpecentes foram apreendidos um quiosque em uma área verde (fls. 131-132), local que além de não constar no rol da lei de regência, tampouco se enquadra como "recinto onde se realizam diversões de qualquer natureza". Além disso, os guardas municipais afirmaram que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e próximo a uma mata que facilita a prática do tráfico de drogas. Nesse sentido, já julgou o Superior Tribunal de Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREQUESTIONADA NA ORIGEM. RECONSIDERAÇÃO. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI 11.343/06. PRAÇA PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. AGRAVO PROVIDO. 1. Prequestionada a matéria perante o Tribunal de origem, deve ser conhecido o recurso especial. 2. A prática de crime de tráfico de drogas em praça pública, por si só, não atrai a incidência da majorante prevista no

art. 40, III, da Lei 11.343/06, porquanto não prevista em lei, sendo vedado o uso da analogia in malam partem. 3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial e dar-lhe provimento a fim de reduzir a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa, mantido o regime fechado (STJ. AgRg no AREsp 1495549/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)".

Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para a utilização na diminuição da pena.

O legislador não estipulou quais seriam, apenas mencionando dever o magistrado reduzir a pena de um sexto a dois terços. É lógico que há de existir o cuidado de evitar "bis in idem". Na hipótese analisada, o processo em curso não são considerados como maus antecedentes ou reincidência, o réu é tecnicamente primário (fls. 49-50) e não restou provado que ele integra organização criminosa, considerando que a prisão decorreu de abordagem de guardas municipais sem qualquer investigação prévia, a quantidade apreendida não é expressiva: 10 (dez) frascos de "lança-perfume", 3,35 (três gramas e trinta e cinco centigramas) de maconha; 10,29g (dez gramas e vinte e nove centigramas) de cocaína; 15,29 (quinze gramas e vinte e nove centigramas) de crack, conforme destacado no v. Acórdão em fls. 118, a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Salientando-se que inquéritos e ações penais em curso não impedem a aplicação do mencionado redutor. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Tráfico - Suficiência de provas - Manutenção da condenação. Penas - Aumento das básicas por diversidade e natureza dos entorpecentes - Exclusão - Quantidade pouco expressiva - Espécie de um dos tóxicos, por si só, não autoriza exasperação - Critérios cumulados do art. 42 da Lei 11.343/06. Penas - Fixação no piso - Inviável maior diminuição por atenuante - Súmula 231 do STJ. Art. 40, III, da Lei 11.343/06 - Necessidade de demonstração de interesse em propagar o uso de tóxicos entre aqueles que circulam pelos lugares enumerados - Não incidência. Redutor - Cabimento - Réu primário, menor, confesso e sem antecedentes - Redutor máximo - Quantidade não significativa de droga, considerado o peso total. Regime aberto e substituição da pena corporal por restritivas de direitos - Possibilidade. Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502170-63.2019.8.26.0628; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapevi - Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/11/2021; Data de Registro: 09/11/2021)

TRÁFICO DE DROGAS. Conduta de ter em depósito, para fornecimento a consumo de terceiros, 56,8g de maconha, 32,6g de cocaína e de 8,6g de cocaína na forma de crack. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão judicial somada à prova testemunhal, consistente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. Natureza, diversidade, quantidade e modo de acondicionamento. Condenação mantida. PENA. Causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em sua fração máxima. Admissibilidade. Réu primário e de bons antecedentes. Ausência de prova da dedicação a atividades criminosas. Incidência do redutor máximo por conta da pequena quantidade e das circunstâncias judiciais

favoráveis. Concretização em 1 ano e 8 meses de reclusão, mais 166 dias-multa. SUBSTITUIÇÃO da privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Precedente do STF. Fixação do regime aberto. Apelo provido para esse fim. (TJSP; Apelação Criminal 1500316-10.2020.8.26.0366; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mongaguá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 17/02/2021; Data de Registro: 17/02/2021)

APELAÇÃO (recurso apenas defensivo) – Tráfico de entorpecente – Pleito da Justiça Gratuita atendido. "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça" (§ 4º do art. 99 do NCPC), anotando-se, porém, na esteira do sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que "A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos" e que "a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções", até porque pode sobrevir, naquele lustro, "mudança na situação econômica da beneficiária" – No mais, materialidade e autoria delitivas comprovadas – Sem olvido de que "Toda pessoa poderá ser testemunha" (art. 202 do CPP) – , nada foi comprovado em pretório (art. 156 do CPP) que demonstrasse qualquer equívoco, animosidade ou inimizade a retirar a credibilidade da prova testemunhal policial, não se podendo inferir, pois, que houvesse na espécie incriminação sem justo motivo. Seria um contrassenso a sociedade organizada (Estado) arregimentar pessoas para a atividade policial e depois negar-lhes valia no trabalho realizado. Ademais, existe, in casu, testemunha civil também a incriminar a ré – Em casos dessa ordem, onde a traficância imputada não é na modalidade "vender", em nada beneficia a acusada o fato de ela não ter sido avistada contatando outras pessoas e/ou vendendo-lhes o estupefaciente, nem mesmo a circunstância de nenhum tóxico ter sido encontrado em seu poder no momento da abordagem policial, eis que a increpação é de que ela "guardava" e "tinha em depósito" a droga, afigurando-se desnecessário saber, inclusive, de quem era a propriedade respectiva, posto que, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo – Comprovada a narcotraficância irrogada, impossível a desclassificação para a infração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – Tráfico Privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006).

Cabimento. Como processos e/ou inquéritos em curso não podem ser considerados na fixação da pena-base, em face do princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art.5º, LVII), pela mesma razão também não se afiguram aptos a obstaculizar, ainda no momento dosimétrico (terceira etapa), a figura privilegiada (onde existe a mesma razão, aí há o mesmo direito: ubi eadem ratio ibi idem ius). (STF e STJ) – Indemonstradas circunstâncias outras a obstar a benesse legal, a aplicação de tal redutor legiferado deve se dar no máximo legal (2/3), dado que o tóxico apreendido o foi em pequena quantidade (menos de 4 gramas de crack), com regime inicial aberto (diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, da primariedade e do quantitativo sancionatório), como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto (CP, art. 33, §2º, "c", e §3º, c.c. o art. 59, caput, in fine, e III, e com o artigo 42 da Lei de Drogas) – Inconstitucionalidade do valor da pena de multa prevista na Lei Antidrogas – Inocorrência. A Lei nº 11.343/2006 é especial em relação ao Estatuto Repressivo (art. 49), de modo que, com rigores sancionatórios ínsitos à inafastável necessidade de se tutelar a saúde pública, deve prevalecer sobre a regra geral (lex specialis derogat legi generali), sem qualquer inconstitucionalidade, até porque editada pelo Poder Legislativo, a quem cabe, na sua tarefa de satisfação do interesse público, não só definir os tipos penais, mas também estabelecer as respectivas sanções. Toda e qualquer punição estatal advinda de condenação criminal repercute, de uma maneira ou de outra, no ius ambulandi do sentenciado, com inegável reverberação econômica não só à sua pessoa, como também àqueles que dele monetariamente dependam. Mas isso não pode significar, por óbvio, violação à intranscendência subjetiva das sanções, albergada no artigo 5º, XLV, da Constituição da República; as normas constitucionais não comportam interpretações estanques, devendo coexistir contextualmente, e, assim, também permitir a apenação daqueles que infringirem a normatividade penal posta, como se depreende de vários dos incisos hospedados

naquele mesmo artigo 5º. Tem-se, nesse contexto, a busca do primado maior da Justiça, de se dar a cada um o que é seu (suum cuique tribuere), inclusive individualizando-se a pena, como expressamente contemplado no citado artigo 5º, desta feita no inciso XLVI, e dessa forma possibilitar o respeito à harmonia e ao bem-estar sociais, consoante o preâmbulo da mesma Lei das Leis - Presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena corporal por duas restritiva de direitos, a teor da segunda parte do § 2º (quantum superior a 1 ano) do artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Inviável tal permuta "por multa"; diversamente, se estaria desnaturando a mens legis, que cominou à espécie, cumulativamente, reprimenda prisional e (também) multa, de maneira que a aplicação de uma nova pena de multa não se afigura socialmente recomendável em casos que tais, pois, em última análise, ter-se-ia como resultado somente sanção pecuniária (STJ) - DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1501447-21.2019.8.26.0571; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021).

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é tecnicamente primário (fl. 49-50), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime não devem ser valoradas negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade das penas aplicadas, sendo o réu primário, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu LUAN CARLOS LIMA SANTOS, à pena de da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicados.

Expeça-se alvará de soltura.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet. Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 24 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA